

1500155-85.2021.8.26.0585

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Magistrado: DEYVISON HEBERTH DOS REIS

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... informações sobre operações de tráfico de drogas e relações de contas bancárias. Afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoa desconhecida. Há elementos que comprovam que a ré estaria associada a seu amasio, para fins de tráfico. E nas palavras do renomado jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

"indícios múltiplos, concatenados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

3ª Vara

Avenida Faustino Rodrigues Azenha, 1500, Presidente Venceslau-SP - cep 19400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500155-85.2021.8.26.0585 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500155-85.2021.8.26.0585

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2220767/2021 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU PLANTÃO, 19624784 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU

PLANTÃO, 1466/21/624 - DEL.SEC.PRES.VENCESLAU PLANTÃO, 2220767 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU, 1466/21/624 - DEL.INV.GER. PRES VENCESLAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAMARA CRISTINA LIMA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DEYVISON HEBERTH DOS REIS

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de TAMARA CRISTINA LIMA DA SILVA e JOSUEL SILVÉRIO DE FREITAS, qualificados nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 35, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, em data incerta, mas anteriormente ao dia 14 de agosto de 2021, os denunciados associaram-se, com a finalidade de explorarem o tráfico de drogas.

Narra a denúncia que TAMARA e JOSUEL mantêm relacionamento amoroso e, estando ele custodiado na Penitenciária II desta cidade e comarca, recebe as visitas constantes da denunciada. Neste contexto, eles deliberaram por constituir a associação, ficando TAMARA encarregada do envio de comunicações e manuscritos de JOSUEL a pessoas que se encontram fora do ambiente prisional. Consta que, no último dia 14 de agosto, após realizar a visita periódica a JOSUEL, TAMARA recebeu dele uma carta e quatro pedaços de papel contendo manuscritos que elencavam informações sobre operações de tráfico de drogas e relações de contas bancárias, com o objetivo de retirá-los ergástulo. Em um dos manuscritos há menção de uma conta bancária, ainda a ser identificada, e, no verso deste pequeno pedaço de papel, consta a alcunha "ZIEL X-16", pela qual JOSUEL é conhecido. Quanto à carta que TAMARA tencionava retirar do presídio, contém em um de seus trechos a menção de que uma pessoa, que liga para "MARIA", vai trazer (para o presídio) um "EMBRULHO", contendo ainda a indicação "faça bem feito" deixando claro que a correspondência continha uma ordem para execução de tarefa por seu destinatário. Logo depois, ainda nesta carta, o interlocutor que escreve o manuscrito fala que "os dois se junta aí" para obter a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) mais uma quantia para obter o material do "embrulho". Logo mais adiante, o escritor do documento menciona que "quem vai pega a folha K4" (substância entorpecente de caráter sintética) é outra pessoa, que fará uma ligação logo depois. Vale mencionar que o "K4" é uma modalidade de entorpecente produzido na forma líquida para embeber papéis, cartões, fotografias e outros documentos na tentativa de ludibriar o processo de fiscalização e, assim, ganhar ingresso fácil ao sistema prisional. Em outro manuscrito, há menção a valores a receber e as contas para as quais devem ser direcionados, sendo alguns deles de monta considerável, tais como "R\$ 2660,00 outro de R\$ 2660,00 novamente", contendo ainda a informação de que resta o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Logo mais abaixo, outros valores são mencionados, todos direcionados a pessoas do convívio daquele que escreveu. O que mostra que os denunciados optam por usar contas de terceiros para realizar movimentação do tráfico, a fim de "camuflar" e esconder o acúmulo de valores obtidos. Todavia, agentes de segurança penitenciária que efetuavam o controle do ingresso e da saída de visitantes no interior da unidade prisional perceberam quando TAMARA tentou sair do estabelecimento prisional com um volume anormal no cós da calça que trajava. Submetida ao aparelho de scanner corporal, foi acusada a presença da carta e dos demais pedaços de papel, os quais foram posteriormente apreendidos.

A acusada foi presa em flagrante delito, e por força de decisão fundamentada de fls. 53/62, foi convertida em prisão preventiva. Em relação ao acusado, este já se encontrava preso, portanto, seu estado permaneceu inalterado.

Em Habeas Corpus (fls. 204/220), foi indeferida a liminar impetrada pela Defesa objetivando a conversão da prisão preventiva, da acusada, em domiciliar.

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fls. 188/190).

Citação/notificação efetivada às fls. 138 e 144. Defesa preliminar às fls. 160/166. Em audiência de instrução realizada virtualmente em razão da suspensão do expediente forense devido à pandemia pelo COVID19, foram interrogados os réus e inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes. Encerrada a fase instrutória, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação e condenação dos réus nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, advogou teses absolutórias. Sobrevieram informes acerca do julgamento do mérito do Habeas Corpus impetrado em favor da acusada TÂMARA (fls. 261/265), concedendo-se-lhe a prisão domiciliar com medidas cautelares. A ordem foi cumprida por este juízo (fls. 266/270).

Os autos vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Os elementos de convicção extraídos dos autos impõem a procedência da ação penal. A materialidade do delito está evidentemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 13/15, o auto de exibição e apreensão de fl. 21, os documentos de fls. 22/31 e o relatório de investigação de fls. 78/82, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Também não remanesce dúvida quanto à autoria.

A ré, em fase inquisitiva, na presença de sua advogada, disse que realizou a visita de seu esposo JOSUEL SILVÉRIO DE FREITAS e no final da visita, ele disse que "tinha uns recados para pegar", mas não disse o que era e quando estava saindo a interrogada resultou pegar uns papéis contendo anotações, mas não chegou a ler o conteúdo. Resolveu pegar os manuscritos por vontade própria e que seu esposo não exigiu nada. Declara que não sabia para quem deveria entregar os manuscritos. Por fim, declara que tem uma filha de seis anos, a qual reside em sua companhia na cidade de Caldas Novas/GO. Sofre de epilepsia e que toma medicamentos de uso controlado, sendo certo que não trouxe o medicamento. Em juízo, disse que avistou um plástico pequeno, enquanto visitava Josuel; que o plástico estava localizado no tanque; que pegou a embalagem por curiosidade e inocência; que não sabia o conteúdo da embalagem; que somente a pegou por curiosidade; que Josuel não lhe disse nada referente a "recados" que ela deveria pegar; que não prestou tais declarações na delegacia de polícia; que está grávida, e sua gravidez é de risco; que não está recebendo visitas de seus familiares, somente recebeu uma carta de sua avó.

O réu, sob solo policial, afirmou que não tem ciência dos fatos, não tendo dado nada a ela e não pedindo para sair com nada. Se pegou os papéis, o fez na Radial, com alguma visita que pediu para ajudar. Não tem envolvimento com tráfico e tampouco com esse tipo de papel que não é de seu conhecimento. Em juízo, disse que não tem envolvimento algum com os fatos, e que sempre orientou Tamara a não atender pedidos de estranhos, e não confiar em estranhos; que não tem ciência dos fatos, não sabe como ela conseguiu os papéis.

A Condutora e Primeira Testemunha Viviane de Jesus Henriques Coimbra, agente de segurança penitenciária, estava no exercício de suas funções quando foi recepcionada a autora, a qual passou pela revista por intermédio do escâner corporal e como nada de irregular foi constatado, a visitante foi liberada e entrou para realizar a visita. Esclarece que quando a autora estava saindo da unidade prisional, já no final do período de visita, foi possível visualizar um volume no cós da calça que a autora trajava. Ocasão em que foi abordada e encaminhada ao escâner corporal e então, foram localizados alguns papéis manuscritos dobrados envoltos em um pedaço de plástico. Com isso, a autora foi questionada sobre os manuscritos e alegou que ela estava no raio com seu marido (JOSUEL SILVÉRIO DE FREITAS, matrícula 98438, do Raio III, cela 16), tendo ele pedido que ela pegasse os manuscritos em um local no raio, manuscritos estes que seriam de propriedade de outro sentenciado citado por ela como WANDERLEI MACAMBIRA DE BRITO, matrícula 231130, Raio III, cela 08) e levasse para fora da penitenciária. Com isso, esclarece a depoente que analisando os manuscritos constatou que havia referência a movimentação de drogas do tipo "K4", valores em dinheiro com indicação de algumas contas bancárias. Ainda, esclarece que com base nas informações prestadas pela autora, efetuou consulta no banco de dados e constatou que a esposa do sentenciado proprietário dos manuscritos é Maria de Sousa Oliveira Macambira, residente na cidade de São Bernardo do Campo/SP, na Travessa Nova, 6-A, Jardim Ipê, a qual não se fazia presente nesta data.

A testemunha Cristiane Aparecida dos Santos Scalão se pronunciou da mesma forma. Em juízo, disse que Tamara entrou, pela manhã, para visitar um sentenciado, e, ao retornar, pôde perceber que havia um volume nas vestes de Tamara, momento em que a conduziu até o scanner corporal; que levaram a acusada até a sala onde foi realizada a revista, e nesta oportunidade, ela entregou os papéis que carregava; que ao perceber que ela carregava vários manuscritos, solicitou o apoio da Polícia Civil, para realizar a investigação desses manuscritos; que Tamara, no momento, admitiu os fatos e revelou que praticou o delito a pedido de seu marido e também

corréu, Josuel.

O investigador de Polícia Luciano Jean Esposto disse laborar no plantão policial, sendo certo que foi apresentado pela condutora desta ocorrência, VIVIANE DE JESUS HENRIQUES COIMBRA, que é Agente Penitenciária, a indiciada TAMARA e alguns papéis manuscritos. Assim, em análise prévia a tais documentos, pôde observar que havia informações sobre contas bancárias, além de menção a entorpecentes, no caso, "mato", referência ao entorpecente conhecido como maconha, e K4, que também é substância entorpecente. Ainda, em tais manuscritos havia menção de que pessoas de fora da penitenciária estariam preparadas para ingressar com as substâncias, e outras pessoas seriam contatadas para fornecer as embalagens e valores a serem pagos. Em juízo, disse que por meio da análise das anotações pode notar que se tratava de contabilidade relativa ao tráfico de drogas; que não se recorda de todos os detalhes observados à época da análise, haja vista o tempo decorrido.

Pois bem.

Em proêmio, consigno que se presume regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra. É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06). Nesse sentido ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TERSTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS- O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Nesse diapasão, o Colendo Supremo Tribunal Federal:

"A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente."

Os agentes públicos ouvidos em juízo apresentaram depoimento harmônico e coerente quanto à localização dos manuscritos, todos em posse de Tamara, os quais continham informações sobre operações de tráfico de drogas e relações de contas bancárias. Afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoa desconhecida. Há elementos que comprovam que a ré estaria associada a seu amasio, para fins de tráfico. E nas palavras do renomado jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

"indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficiente para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado". (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Prosseguindo, observo que, em sede policial, a ré confessou a prática do delito e

admitiu estar carregando manuscritos, dizendo ainda que, embora desconhecesse o conteúdo, transportava os papéis a pedido do corréu Josuel Silvério.

A alegação da ré de que desconhecia o conteúdo dos manuscritos apreendidos, ainda que fosse admitida como verdadeira, não obsta a caracterização do crime. É evidente que, no mínimo, agiu com dolo eventual, incorrendo no art. 35 da Lei 11.343/06, mesmo porque, estando na condição de companheira de Josuel, a acusada deveria conhecer a personalidade de seu amásio, pessoa totalmente dada às práticas criminosas, sendo, inclusive, já condenado pelo tráfico de entorpecentes, conforme se denota às fls. 128/136. Outrossim, é evidente que Tamara, no mínimo, acreditava na ilicitude do conteúdo dos manuscritos que transportava, até porque valeu-se de meio não permitido para tentar retirar-os do presídio, ocultando-os no cóis de sua calça. Sabia ela, portanto, que com a entrega desses objetos ao devido destinatário, prestaria valioso auxílio a Josuel.

Como se não bastasse, o elemento subjetivo fica claro por aplicação da Doutrina da Cegueira Deliberada, conhecida no Direito Anglo Saxão por Willfull Blindness Doctrine, "Ostrich Instructions" (Instruções de Avestruz) ou "Conscious Avoidance Doctrine" (Doutrina do Ato de Ignorância Consciente), segundo a qual o agente finge não enxergar a ilicitude da procedência de (ou dos próprios) bens e/ou valores, com a intenção deliberada de auferir vantagens. Por meio dessa teoria, busca-se sancionar o agente que, de modo deliberado/proposital, coloca-se em estado de ignorância ou desconhecimento visando não conhecer detalhes das circunstâncias fáticas que circundam uma situação suspeita.

Em suma, acerca dos interrogatórios dos réus em juízo, "as versões apresentadas, absolutamente falaciosas, é a consagração da 'teoria da cegueira deliberada' willful blindness, popularizada com a expressão 'instrução do avestruz', em que o agente infrator como linha de defesa renuncia à conscientização da ilicitude da conduta" (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0000614-29.2012.8.26.0246).

Discorrendo acerca da "potencial conhecimento da ilicitude" como componente da culpabilidade, o Professor Luiz Regis Prado (in "Curso de Direito Penal Brasileiro", vol. I, RT, 2ª ed., pág. 275), leciona o seguinte:

"É elemento intelectual da reprovabilidade, sendo a consciência ou o conhecimento atual ou possível da ilicitude da conduta. Trata-se, então, da possibilidade de o agente poder conhecer o caráter ilícito de sua ação consciência potencial (não real) da ilicitude. Para esse conhecimento (profano), 'basta que o autor tenha base suficiente para saber que o fato praticado está juridicamente proibido e que é contrário às normas mais elementares que regem a convivência'".

Já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região que "a potencial consciência da ilicitude é elemento da culpabilidade, que não necessita ser efetiva. Basta que o agente, com algum esforço ou cuidado, saiba que o fato é ilícito" (Ap. 2005.72.00.050844-9-SC, 8ª Turma, j. 12.07.2006).

Saliente-se que, no tocante à permanência e estabilidade da associação, depreende-se que a própria ré confirma que já visitava o corréu Josuel há bastante tempo, tendo suspenso as visitas tão somente em decorrência da pandemia. Logo, considerando que a acusada tinha ciência do envolvimento de Josuel com o tráfico de drogas, bem como tendo em vista que anuiu levar para fora da unidade prisional de segurança máxima o que denominou de "uns recados" (fl. 07), tendo tal informação (confissão) sido confirmada pela testemunha Cristiane em juízo, é evidente o estabelecimento de verdadeira societas sceleris não só com o remetente, mas também com os destinatários da informação, que, diga-se, não precisam se tratar de pessoas conhecidas dos acusados.

Adiante, na análise dos manuscritos apreendidos (fls.78/82), foi possível identificar a alcunha "ZIEL X-16", que, ao ser confrontada com o banco de dados da Polícia Civil, revelou tratar-se da pessoa de Josuel Silvério de Freitas, companheiro de Tamara, corroborando assim, o informado pela ré. A propósito, a alcunha identifica exatamente o número da cela em que o acusado Josuel cumpria pena, rechaçando, de uma vez por todas, que o referido apelido pudesse se referir a outra pessoa.

Nesse sentido, também sobejam provas em desfavor do corréu Josuel, sendo certo que

se associou com Tamara Cristina para praticar o crime de tráfico de drogas. Ademais, não há nos autos qualquer prova em favor dos acusados, ou seja, apta a desmantelar o arcabouço probatório formado na instrução. Verifico, ainda, que o conjunto probatório está formado não somente pelo teor dos depoimentos dos mencionados agentes, mas também pela prova documental e pericial (análise dos documentos) produzida.

Eventualmente, poder-se-a cogitar da ocorrência do crime previsto no art. 37 da Lei 11.343/06. No entanto, este é subsidiário ao crime do art. 35 da mesma lei, de sorte que, estando caracterizadas as elementares deste último tipo penal (caracterizando-se o envolvimento do agente na associação para o tráfico, de forma permanente e estável), aquele delito fica por este absorvido.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. DELITO DE COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. ART. 37 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESSUPOSIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ENVOLVIMENTO COM O GRUPO, ASSOCIAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO. DIVISÃO DE TAREFAS. FUNÇÃO INTERNA DE SENTINELA, FOGUETEIRO OU INFORMANTE. CONFIGURAÇÃO DE TIPO PENAL MAIS ABRANGENTE. TRÁFICO OU ASSOCIAÇÃO. 3. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO. ARTS. 35 E 37 DA LEI Nº 11.343/2006. AGENTE QUE EXERCE FUNÇÃO DE INFORMANTE DENTRO DA ASSOCIAÇÃO DA QUAL PARTICIPA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA APENAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. 4. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CASSAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 37 DA LEI Nº 11.343/2006 E ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal. 2. A norma incriminadora do art. 37 da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o agente que colabora como informante com grupo (concurso eventual de pessoas), organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.694/2012) ou associação (art. 35 da Lei nº 11/343/2006), desde que não tenha ele qualquer envolvimento ou relação com as atividades daquele grupo, organização criminosa ou associação para as quais atua como informante. Se a prova indica que o agente mantém vínculo ou envolvimento com esses grupos, conhecendo e participando de sua rotina, bem como cumprindo sua tarefa na empreitada comum, a conduta não se subsume ao tipo do art. 37 da Lei de Tóxicos, mas sim pode configurar outras figuras penais, como o tráfico ou a associação, nas modalidades autoria e participação, ainda que a função interna do agente seja a de sentinela, fogueteiro ou informante. 3. O tipo penal trazido no art. 37 da Lei de Drogas se reveste de verdadeiro caráter de subsidiariedade, só ficando preenchida a tipicidade quando não se comprovar a prática de crime mais grave. De fato, cuidando-se de agente que participa do próprio delito de tráfico ou de associação, a conduta de colaborar com informações para o tráfico já é inerente aos mencionados tipos. Considerar que o informante possa ser punido duplamente, pela associação e pela colaboração com a própria associação da qual faz parte, além de contrariar o princípio da subsidiariedade, revela indevido bis in idem. 4. Além de o § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990 ter sido considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o crime de associação nem sequer é equiparado a hediondo, não havendo se falar, portanto, em regime fechado decorrente de imposição legal. Fixada a reprimenda no mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias

negativas, mostra-se adequada a aplicação do regime aberto, nos termos do que disciplina o art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar a condenação pelo delito descrito no art. 37 da Lei nº 11.343/2006, mantendo apenas o édito condenatório pelo crime de associação, alterando-se, no mais, o regime de cumprimento da pena para o aberto. (HC 224.849/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013).

Por derradeiro, por estar comprovado nos autos que o crime foi praticado no interior da Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira de Presidente Venceslau/SP, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Passo então a dosar a reprimenda.

Quanto à ré TAMARA CRISTINA LIMA DA SILVA:

Na primeira fase da dosimetria penal, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (a acusada é absolutamente primária); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena com base no mínimo legal, haja vista as boas circunstâncias judiciais da ré, perfazendo-se em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que restam ausentes quaisquer circunstâncias agravantes a serem consideradas. Contudo verifica-se presente a atenuante da confissão realizada na fase administrativa, entretanto, como a pena já está fixada no patamar mínimo, permanece inalterada. Inteligência da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase de dosimetria da pena, está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, que prevê aumento de 1/6 a 2/3 se a infração tiver sido cometida nas dependências de estabelecimentos prisionais. Considerando que a infração foi cometida no interior de estabelecimento penal de segurança máxima, local onde estão presos líderes de facção criminosa conhecida, que atua dentro e fora dos presídios, controlando todo o tráfico de drogas no Estado de São Paulo, entendo que é o caso de se aumentar a pena em 1/2, perfazendo-se 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa. Torno esta a pena definitiva, na ausência de demais circunstâncias modificadoras.

Levando-se em consideração a míngua de informações concretas acerca da situação econômico-financeira da ré, fixo o valor unitário do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos até o pagamento efetivo.

O regime de cumprimento da pena será o semiaberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Impedida e não recomendada a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, pois a pena ultrapassou o período de quatro anos (art. 44, I, do CP). Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar o sursis penal.

Quanto ao réu JOSUEL SILVÉRIO DE FREITAS:

Na primeira fase da dosimetria penal, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (sua culpabilidade destoa do normal à espécie delitiva, pois o delito foi cometido com extrema audácia e ousadia, demonstrando o atrevimento do réu, que mesmo tendo ciência de blitz, revistas e eventuais diligências que ocorrem frequentemente nos presídios, tentou transpor os muros da penitenciária de segurança máxima no sentido de transmitir, por meio das missivas apreendidas, informações para pessoas associadas ao tráfico de entorpecentes); antecedentes (o acusado ostenta inúmeras condenações em seu nome, como faz certa a certidão de fls. 128/136, de modo que uma delas será usada na primeira fase como Maus Antecedentes, e as demais serão consideradas na fase subsequente, para fins de reincidência); conduta social (nada a considerar);

personalidade (nada a considerar); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu, bem como sua culpabilidade, majoro a reprimenda na razão de 1/3, perfazendo-se em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que restam ausentes quaisquer circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Contudo, verifica-se presente a agravante da reincidência (fls. 128/136), razão pela qual aplico no aumento, na razão de 1/6, perfazendo-se em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria da pena, está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, que prevê aumento de 1/6 a 2/3 se a infração tiver sido cometida nas dependências de estabelecimentos prisionais. Considerando que a infração foi cometida no interior de estabelecimento penal de segurança máxima, local onde estão presos líderes de facção criminosa conhecida, que atua dentro e fora dos presídios, controlando todo o tráfico de drogas no Estado de São Paulo, entendo que é o caso de se aumentar a pena em 1/2 (metade), perfazendo-se em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 1632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa. Torno esta a pena definitiva, na ausência de demais circunstâncias modificadoras.

Levando-se em consideração a míngua de informações concretas acerca da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor unitário do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos até o pagamento efetivo.

O regime de cumprimento da pena será o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Em vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu, resta impedida e não recomendada a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos (art. 44, II, do CP). Em razão do montante de pena aplicada, bem como considerando a reincidência e os maus antecedentes do acusado, deixo de aplicar o sursis penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na inicial, e o faço para:

(1) CONDENAR a ré TAMARA CRISTINA LIMA DA SILVA, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, fixadas estas em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 35, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

(2) CONDENAR o réu JOSUEL SILVÉRIO DE FREITAS, ao cumprimento de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, fixadas estas em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 35, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

INDEFIRO ao réu JOSUEL SILVÉRIO DE FREITAS o direito de apelar em liberdade, visto que permaneceu preso durante o curso do processo, estando ainda mais veementes os requisitos da Prisão Preventiva, haja vista a presente condenação sob juízo de cognição vertical exauriente. Observo que o acusado não faz jus ao benefício de recorrer em liberdade, pois, consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: "inaplicável, a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória (RHC 177 - RJ-5; Cfm. do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89). Pois, seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelos mais" (RT 504/339). Recomende-se o réu JOSUEL SILVÉRIO DE FREITAS na prisão em que se encontra.

Por outro lado, considerando que a ré TAMARA CRISTINA LIMA DA SILVA encontra-se em prisão domiciliar por força de decisão proferida no do Habeas Corpus nº 2273695-37.2021.8.26.0000 (fls. 261/265), assim deverá permanecer.

Custas ex legis.

Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Autorizo a destruição dos objetos apreendidos. Cumpridas as finalidades legais, archive-se.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 17 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA